

1500510-93.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE LEVY PERRUCCI

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTH MATEUS DE TOLEDO CUNHA

V I S T O S.

ROBERTH MATHEUS DE TOLEDO CUNHA está sendo processado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput c.c. artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), observadas as disposições da Lei 8.072/90 porque, conforme consta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Pindamonhangaba-SP - cep 12421-010

1500510-93.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500510-93.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTH MATEUS DE TOLEDO CUNHA

V I S T O S.

ROBERTH MATHEUS DE TOLEDO CUNHA está sendo processado como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput c.c. artigo 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas), observadas as disposições da Lei 8.072/90 porque, conforme consta na denúncia:

1. A partir de data incerta e até o dia 06 de abril de 2021, neste município, nesta Comarca, ROBERTH MATEUS DE TOLEDO CUNHA associou-se ao adolescente G.H.D.J.C.S., com 16 anos de idade ao tempo do fato, para o fim de praticar os crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e
2. No dia 06 de abril de 2021, até por volta das 19h35min, na Rua João Batista de Almeida, nas proximidades do nº 20, Araretama, neste município, ROBERTH MATEUS DE TOLEDO CUNHA, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de propósito com o adolescente G.H.D.J.C.S., guardava e tinha em depósito, bem como trazia consigo, para entregar e fornecer a consumo de terceiros, 31 porções de cocaína, com peso líquido total de 12,35 gramas, 19 porções de "crack", constituído por

cocaína, com peso líquido total de 3,14 gramas, e 3 porções de Cannabis sativa l., popularmente conhecida como "maconha", contendo tetraidrocanabinol, com peso líquido total de 6,4 gramas, drogas aptas a causarem dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão às fls. 28/29.

Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 32/37.

Fotografias às fls. 38/44.

Às fls. 62/64, no Plantão Judiciário, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva.

Laudo químico toxicológico às fls. 103/105.

Manutenção da prisão preventiva às fls. 115/116.

Defesa às fls. 117/118.

A denúncia foi devidamente recebida às fls. 121/123.

Manutenção da prisão preventiva às fls. 128.

Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu (138/139).

Em alegações finais orais, a promotoria requereu a procedência parcial da ação, com absolvição do acusado quanto à associação ao tráfico. Manifestou-se quanto à dosimetria da pena (fls. 138/139).

Manutenção da prisão preventiva às fls. 144

A Defesa pugnou pela absolvição e, em caso de condenação, postulou pela aplicação das atenuantes da menoridade relativa, da confissão, da aplicação da causa de diminuição do parágrafo quarto do artigo 33, afastamento da causa de aumento, detração penal e isenção de custas processuais (fls. 147/149).

É o relatório

D E C I D O.

O policial militar Juarez informou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando visualizaram dois indivíduos. Disse que, ao perceberem a presença da polícia, um deles retirou algo da cintura e dispensou ao solo. Relatou que, em abordagem pessoal, com Roberth, indivíduo que dispensou o objeto, nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R\$9,00. Informou que o adolescente Gabriel, de pronto, contou que havia drogas em sua cintura, sendo um pacote plástico com 17 pinos de cocaína, 09 porções de crack e 03 invólucros de maconha. Disse que, no local onde foi dispensado o objeto, encontraram um pacote plástico com 14 pinos de cocaína, idênticos aos que estavam com o menor. Relatou que, informalmente, ambos confirmaram que venderiam as drogas em uma praça próxima. Contou que o acusado residia em local próximo e, com a autorização da genitora, verificaram o quarto de Roberth e nada de ilícito foi localizado. Negou conhecer o acusado e o adolescente. O acusado, em juízo, confirmou que estava com 14 pinos e na companhia do menor e, quando viu a polícia, tentou dispensar a droga. Confirmou que iriam vender as drogas. Disse que fazia cinco ou seis dias que estava vendendo entorpecentes. Negou passagens, inclusive quando adolescente. Confirmou que estava com o adolescente no ponto de venda juntos. Disse que havia saído do quartel há dois meses.

Na fase policial, contou a mesma versão dos fatos.

A ação penal é parcialmente procedente.

Crime do artigo 35 da Lei 11.343/06

Como bem observado pelo ilustre Promotor de Justiça oficiante no feito em sua última manifestação, a análise do conjunto probatório produzido não permite concluir pela existência de prova segura de que o acusado Roberth tenha praticado o delito.

Desta forma, ACOLHO a fundamentação do Ministério Público como causa de decidir, para absolver o acusado.

2. Crime do artigo 33 da Lei 11.343/06

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo químico toxicológico, bem como pela prova oral produzida.

De acordo com o que consta dos autos, os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento quando avistaram dois indivíduos, sendo que um deles dispensou um

objeto. Constataram que o acusado havia dispensado o objeto, que seria um pacote com 14 pinos de cocaína; com o outro indivíduo, um adolescente, também localizaram drogas, maconha, cocaína e crack.

O acusado, tanto na fase policial, quanto em juízo, confessou o cometimento do crime, confirmando a posse das porções de cocaína e que estava na companhia do adolescente vendendo drogas. Confirmou, ainda, que estava vendendo drogas há cerca de cinco, seis dias.

A confissão está de acordo com as provas colhidas nos autos.

De rigor, portanto, a condenação de Roberth, com a causa de aumento do cometimento do crime na companhia de adolescente (artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06).

Passo a dosar as penas.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, bem como as condições do artigo 42 da Lei 11.343/06 não são favoráveis ao acusado, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos (31 porções de cocaína, 19 porções de crack e 03 porções de maconha). Assim, fixo a pena-base em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reduzo a pena em 1/5, resultando em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6, resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Verifico presente a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que preenchidos os requisitos objetivos para a obtenção do benefício. Quanto ao montante da diminuição, diante do silêncio da lei, serão adotadas as circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06, de forma preponderante, além das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, como forma de cumprir o princípio da individualização da pena, decorrente da isonomia, tratando-se de forma igual os iguais, e desigual os desiguais, na medida exata das desigualdades. Nesse sentido, destaco trecho de V. Acórdão do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 109193/MG, relatado pelo Ministro Teori Zavascki, julgado em 19/12/2013: "Quanto à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, destacou-se que ambas as Turmas entenderiam que essa minorante estaria condicionada ao preenchimento, de forma cumulativa, dos requisitos de primariedade, de bons antecedentes e de que o agente não se dedicasse a atividades criminosas nem integrasse organização criminosa. Aduziu-se que esses critérios negativos seriam, portanto, excludentes da possibilidade de redução da pena, porque, se não estiverem todos presentes, inviabilizam a incidência do dispositivo. Ponderou-se que esses critérios revelariam a dificuldade de saber quais balizas deveria o julgador levar em conta para definir o quantum de diminuição, mormente em face da largueza da faixa admissível: de um sexto a dois terços. Considerou-se que, ante a ausência de critérios preestabelecidos para a escolha do quantum de diminuição na terceira fase da dosimetria, uma vez que a lei não colocaria à disposição do julgador nenhum dado que pudesse servir de parâmetro, não se vislumbraria contrária ao direito a possibilidade de o julgador socorrer-se de uma ou mais circunstâncias descritas no art. 42 da Lei de Drogas." Com a finalidade de afastar a alegação de bis in idem, conforme recente decisão também do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (HC 112776/MS), apenas aquelas circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas ou do artigo 59 do Código Penal não utilizadas na primeira fase de dosimetria da pena podem ser valoradas para obtenção do quanto de diminuição. Na primeira fase foi utilizada a natureza da droga, podendo agora ser analisada a qualidade (cocaína, crack e maconha). Assim, reduzo a reprimenda em 1/5, resultando a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão, e 466 dias-multa.

Considerando a capacidade econômica do réu, com fundamento no artigo 43 da Lei 11.343/06, fixo o valor de cada dia multa em 1/30 do valor do salário mínimo nacional.

Quanto ao regime inicial do cumprimento de pena, verifico que o artigo 33, §3º do Código Penal determina a observância dos critérios do artigo 59 do Código Penal, o que deve ser interpretado à luz do artigo 42 da Lei de Drogas, que prevê a predominância dos seguintes critérios: natureza e quantidade das drogas, personalidade e a conduta social do agente.

Este juízo tem entendido, frente à experiência nesta Vara Criminal, que a natureza da droga deve ser especialmente analisada quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Dentre os tipos de entorpecentes, a maconha é a espécie de efeito menos perturbador para o organismo, em que pese estar classificada dentre os alucinógenos. Desta forma, em casos de apreensão de pequenas quantidades de maconha, o regime aberto é o mais indicado.

No que tange à cocaína, tem-se um quadro diferenciado. Trata-se de droga estimulante da atividade mental, com efeito rápido e duração breve, aumentando-se progressivamente as doses consumidas. Neste caso específico, fixar-se-á o regime inicial semiaberto para a apreensão de pequenas quantidades de cocaína e, também, para grandes quantidades de maconha, posto que, desta feita, denota-se maior periculosidade do agente.

Por sua vez, a droga de maior expressividade maléfica, o crack causa dependência severa rapidamente, às vezes, com poucas semanas de uso. Trata-se de entorpecente com efeito devastador na sociedade, fazendo com que os consumidores, para sustentar o vício, pratiquem crimes de natureza grave, tais como roubo, homicídio e estupro. Neste juízo, verificou-se um caso de estupro cometido pelo filho, dependente de crack e sob seus efeitos, em face da própria mãe (autos nº 0004626-

37.2013.8.26.0445). Portanto, não há que se falar em outro regime para início do cumprimento da pena que não o fechado, que também será o escolhido caso sejam apreendidas grandes quantidades de cocaína.

Por fim, o tipo de entorpecente apreendido com o acusado é um dos indicativos do regime inicial a ser aplicado, contudo, outros elementos serão levados em conta quando da fixação: quantidade da droga, condições pessoais do agente, tais como reincidência, maus antecedentes, tempo de prisão processual, entre outros.

Foram apreendidos 31 porções de cocaína, 19 porções de crack e 03 porções de maconha. Tendo em vista este dado, a gravidade concreta do delito, o quantum da reprimenda, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o tempo de prisão processual, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

1. ABSOLVER o réu ROBERTH MATHEUS DE TOLEDO CUNHA, da prática do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal e

2. CONDENÁ-LO à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, após análise da detração penal, e 488 dias-multa, por incurso no artigo 33, §4º c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Vedo o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o acusado respondeu preso ao processo, tendo em vista que permanecem presentes os requisitos legais.

Assim, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem pública e, também, para assegurar a aplicação da lei penal, a prisão preventiva é medida de rigor.

Muito embora vigore no ordenamento jurídico pátrio o princípio da não culpabilidade ou de presunção de inocência, tal presunção fora mitigada ao longo do processo. O flagrante e a presente condenação são circunstâncias que mitigam a presunção de inocência, recomendando a manutenção da prisão para garantia de aplicação da lei penal.

Ressalto que a custódia cautelar será mantida em benefício da ordem social, visando a resguardar a sociedade, impedindo que o réu volte a praticar novos delitos e para afastá-los do ponto de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que, de acordo com o próprio acusado, já estava traficando há alguns dias e apenas dois meses depois de deixar o quartel.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que se coaduna com o deste Magistrado: "(...) o decreto objetiva, sobretudo, resguardar a ordem pública retirando do convívio social aquele que, diante dos meios de execução utilizados nas práticas delituosas, demonstra ser dotado de alta periculosidade (...)" (RHC nº 24.453-SP, Ministro Relator OG Fernandes); "(...) Desta forma, não se pode dizer que o Juízo de primeira instância, bem como o Tribunal de origem, incidiram em

constrangimento ilegal, haja vista que suas decisões encontram-se baseadas, como dito, na gravidade efetiva do delito em tese cometido, consubstanciada pelo modus operandi dos agentes envolvidos (...)" (RHC nº 23.426-SP, Ministro Relator Jorge Mussi).

Quanto à garantia da ordem pública, a conduta criminosa do acusado abalou a ordem na sociedade. De acordo com Guilherme de Souza Nucci, "Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente". É o caso dos autos.

Por fim, quanto à aplicação da lei penal, a prisão provisória tem como fito proporcionar ao Estado o exercício de seu direito de punir, visando a impedir eventual fuga do acusado.

Inegável, também, a presença de seus pressupostos, a saber: *fumus comissi delicti* e o *periculum libertatis*.

Recomende-se, observando-se o regime fixado em sentença, servindo a presente como ofício de recomendação.

Se dativo o Defensor, expeça-se certidão de honorários em função dos atos praticados.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs).

Ressalto que o pagamento de custas processuais, no processo criminal, ocorre apenas nos casos de condenação do acusado, conforme se verifica da redação do artigo 4º, §9º, alínea "a" da referida Lei: "nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, será pago, ao final, pelo réu, se condenado".

Em outras palavras, durante o processo, o acusado terá todo o necessário para sua defesa custeado pelo Estado, sem qualquer necessidade de pagamento para se defender, recorrer, produzir provas, ouvir testemunhas etc.

O réu não ingressa nos autos por livre e espontânea vontade, e sim para que o Estado possa apurar sua participação em suposta conduta delituosa.

Além disso, caso não tenha condições de constituir advogado, ser-lhe-á nomeado defensor dativo, às custas do Estado.

Portanto, caberá ao acusado, em havendo trânsito em julgado da sentença condenatória, pagar as custas processuais, como efeito secundário da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ressarcindo parcialmente e indiretamente o Estado, pelas despesas que causou, de forma que não há como se falar em Justiça Gratuita.

Em havendo dinheiro apreendido, deverá ser utilizado, em um primeiro momento, para pagamento das custas processuais e, caso seja insuficiente, o acusado será intimado para complementação.

Em contrapartida, após o pagamento das custas processuais, caso haja quantia remanescente, no caso dos autos, serão destinados ao pagamento das multas e, depois, ao Fundo Nacional Antidrogas (artigo 63 da Lei 11.343/06).

PIC.

Pindamonhangaba, 25 de janeiro de 2022

ALEXANDRE LEVY PERRUCCI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA